

1504735-56.2021.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gabriel de Abreu

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

LEONARDO GABRIEL DE ABREU, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1504735-56.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504735-56.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gabriel de Abreu

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

LEONARDO GABRIEL DE ABREU, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, no dia 8 de março de 2021, por volta das 22:30 horas, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06/2020), na Rua Nassif Damus, nº 60, nesta cidade e comarca, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 2 porções de maconha, com peso líquido de 11,73 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apresentada defesa preliminar (fls. 117/126), a denúncia foi recebida (fls. 141/142). O acusado foi citado (fl. 231).

Na fase de instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 244/248).

Em debates orais, o DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 244/248), ao passo que, em memoriais, a Nobre Defensora postulou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, em caso contrário, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e a aplicação do privilégio, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial aberto, e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fls. 249/256).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fl. 12) e dos laudos de constatação provisória (fls. 22/24) e definitiva de entorpecentes (fls. 77/79), com resultados positivos para THC (maconha), bem como do relatório de investigação com extração de conteúdo dos celulares apreendidos (fls. 99/101) e dos laudos de exame pericial dos aparelhos (fls. 102/105 e 106/108).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Em sede policial, o acusado manteve-se em silêncio (fl. 05).

Em juízo, afirmou que, na data dos fatos, estava em uma praça com uma menina quando foi abordado por policiais militares, que já chegaram ao local com seu amigo Lucas. Trazia consigo apenas uma porção de maconha, que entregaria a Lucas e dele receberia o valor de R\$ 10,00. Informou aos policiais que em sua residência havia mais entorpecente e autorizou que eles realizassem as buscas no imóvel. Em seu quarto, no guarda-roupa, foi localizada dentro de uma pochete uma outra porção de maconha, que era destinada ao seu próprio consumo. Nunca negociou a venda de entorpecentes por meio de redes sociais, esclarecendo que o valor cobrado de Lucas era o mesmo que o interrogando pagava pela porção da droga. Afirmou não ter conhecimento de que tal conduta poderia configurar a prática do narcotráfico. Na data anterior à dos fatos publicara uma foto em que aparecia fumando maconha no grupo intitulado "Araraquara em chamas", tendo sido contatado por Lucas, que lhe

perguntou se teria uma porção da droga para lhe vender, ocasião em que consumiram juntos um baseado. Declarou-se usuário de maconha e, na época dos fatos, trabalhava fazendo entregas e atualmente o faz para uma marmitaria e para o aplicativo iFood. Confirmou que seu celular foi apreendido e nele não havia conteúdo relacionado ao tráfico de drogas. Existiam, porém, mensagens trocadas por meio do WhatsApp e do Facebook Messenger com Lucas, que usava os perfis "Charlie Gabriel" e "Lucas Arruda" (cf. gravação audiovisual de fls. 244/248).

Ocorre que, apesar da versão parcialmente exculpatória exarada pelo réu em juízo, o arcabouço probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que os policiais militares Cardoso e Lopes relataram que, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, visualizaram um transeunte que, ao avistar a aproximação da viatura policial, demonstrou nervosismo e mudou de comportamento, razão pela qual foi abordado. O indivíduo foi identificado como Lucas e em seu poder foi encontrada apenas a quantia em dinheiro de R\$ 10,00. Indagado, ele disse que se dirigia a uma praça para encontrar o réu, pois com ele havia negociado a compra de uma porção de maconha por meio de um grupo restrito no Facebook intitulado "Araraquara em chamás". Com base nas características informadas por Lucas, localizaram o acusado sentado em uma praça situada nas imediações do local. Ele estava em companhia de uma moça e logo foi abordado. Em busca pessoal, sob suas vestes, foi apreendida uma porção de maconha acondicionada em plástico filme. Indagado, o réu negou a prática do tráfico de drogas, mas confirmou que negociara a entrega daquele entorpecente com Lucas por meio de uma rede social. Ele ainda lhes revelou que em sua residência havia uma outra porção da droga e autorizou a entrada no imóvel. A genitora do réu estava no local e acompanhou as buscas no quarto de seu filho, onde foi apreendida uma outra porção de maconha idêntica àquela primeira localizada com o imputado (cf. gravação audiovisual de fls. 244/248).

Lopes ainda acresceu que na ocasião Lucas afirmou já ter comprado entorpecente do réu anteriormente. Esclareceu também que em poder do acusado não foi localizado nenhum petrecho ou objeto usado para consumo da droga.

Por fim, Rosana, mãe do acusado, afirmou que, na noite dos fatos, estava em casa quando acordou com a presença de policiais militares. Franqueou-lhes a entrada no imóvel e acompanhou as buscas realizadas no quarto de seu filho, onde foi encontrada uma pequena porção de droga no interior de uma bolsinha. Ficou surpresa com a prisão de seu filho e aduziu desconhecer o seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas, sabendo apenas que ele era usuário de maconha. Também desconhecia eventual amizade entre ele e Lucas. Não soube precisar se o acusado costumava frequentar grupos ou perfis de redes sociais relacionados à venda de entorpecentes. Na época do ocorrido ele trabalhava durante a manhã no Supermercado Savegnago e à noite fazia bicos como entregador, mas atualmente trabalha em uma marmitaria e faz entregas para o aplicativo iFood (cf. gravação audiovisual de fls. 244/248).

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do réu. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Sabe-se que, havendo confissão espontânea do réu exarada perante a autoridade judiciária – ao menos no que diz com a venda da porção de droga a Lucas –, a jurisprudência é uníssona: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239). E ainda: "A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve

como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa” (RT 625/338).

Na hipótese em exame, a conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida não apenas pela palavra do réu em solo judicial, mas sobretudo pela natureza e forma de acondicionamento do tóxico apreendido (2 invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido total de 11,73 gramas - cf. auto de fl. 12 e laudos de fls. 22/24 e 77/79 -, já separados individualmente para a revenda e entrega a terceiros, cf. fotografias de fls. 24 e 70).

Também houve a apreensão, no mesmo contexto fático, em poder do acusado, de um aparelho celular utilizado como instrumento do crime (cf. auto de fl. 12). Já com a testemunha Lucas foi localizada a quantia em dinheiro que seria usada para a compra da droga trazida pelo imputado na ocasião (R\$ 10,00) - cf. auto de fl. 12 e guia de fl. 74.

Frise-se ainda que, ao ser abordado, Lucas admitiu aos milicianos que era usuário de maconha e, na ocasião, dirigia-se ao local dos fatos para adquirir uma porção da droga do acusado, eis que já havia combinado com ele, pelo grupo do Facebook denominado “Araraquara em chamas”, a compra do entorpecente pelo valor de R\$ 10,00 (fl. 04).

Vale destacar que, apesar da reduzida quantidade de entorpecente apreendido, sua divisão em porções individuais indicava potencial de disseminação entre os usuários compradores da droga.

No tocante ao celular utilizado pelo acusado, o exame pericial realizado no aparelho revelou a existência de mensagens claramente relacionadas ao comércio espúrio por ele praticado ao tempo dos fatos, como se infere do teor dos diálogos mantidos com os contatos “Lucas Arruda” e “Charlie Gabriel”, em que se aludia à boa qualidade da maconha, ao peso e ao valor pelo qual a droga era vendida (cf. relatório de investigação de fls. 99/101 e laudo de fls. 102/105). No mesmo aparelho também foram encontradas imagens de entorpecentes.

Ressalte-se que, apesar de sua negativa em relação ao exercício habitual da narcotraficância, o imputado admitiu, sem reboços, sob o crivo do contraditório, que estava no local dos fatos para entregar a terceiro (Lucas) o entorpecente que trazia consigo, mediante pagamento (dez reais).

Tais aspectos, examinados de forma conjunta, afastam a veracidade da frágil versão parcialmente exculpatória exarada pelo réu em juízo e confirmam a ocorrência, na espécie, da guarda e do transporte da droga para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, outrossim, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de droga, bastando que o agente transporte, traga consigo, guarde ou mantenha em depósito a substância entorpecente, sendo inexigível a traditio para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Afasta-se, por conseguinte, o pleito de desclassificação delitiva formulado pela Defesa Técnica em alegações finais, uma vez que todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que o entorpecente apreendido era pertencente ao réu e se destinava, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros - ainda que de forma gratuita -, não sendo unicamente para o uso próprio do imputado.

Cabe realçar, nesse ponto, que os policiais que atenderam à ocorrência confirmaram em solo judicial que na ocasião o acusado não trazia consigo nenhum petrecho ou

objeto comumente usado no consumo de maconha.

Evidente, assim, que, não sendo para o consumo pessoal do imputado, tal droga seria indubitavelmente destinada ao fornecimento a terceiros.

É consabido, ademais, que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples guarda temporária da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sendo todas elas favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, não obstante a presença das atenuantes genéricas da menoridade do réu na data do fato e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, alínea "d", do citado codex), suas penas não podem ser reduzidas aquém do mínimo legal (Súmula 231 do Colendo STJ).

Outrossim, embora não haja dúvida de que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em face da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tal circunstância em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual, ausente o nexo causal, deve ser afastada a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Confira-se:

"Na segunda fase do cálculo, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Para exata compreensão do tema, confira-se ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "53. Situação de desgraça particular ou calamidade pública: mais uma vez o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. Vale-se da fórmula genérica e depois dos exemplos específicos. Constituem os gêneros da agravante: a) calamidade pública: que é a tragédia envolvendo muitas pessoas; b) desgraça particular do ofendido: que é a tragédia envolvendo uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Como espécies desses gêneros temos o incêndio, o naufrágio e a inundação, que podem ser ora calamidades públicas, ora desgraças particulares de alguém. Ex: durante a inundação de um bairro, o agente resolve ingressar nas casas para furtar, enquanto os moradores buscam socorro." (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401). No caso concreto, embora incontestado o estado de calamidade pública, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime. A conduta do réu, que já não se encontrava em isolamento social, por ser morador de rua, de subtrair os objetos do interior de um carro estacionado em via pública não se amolda a exemplos hipotéticos de quem se aproveita de uma desgraça particular ou coletiva, como incêndio, enchentes, acidentes automobilísticos, entre outros, para praticar crimes contra vítimas que se encontram em posição de maior vulnerabilidade decorrente dessas situações" (TJSP - Apelação nº 1510214-73.2020.8.26.0228 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Xavier de Souza - j. 14.09.2020).

Por fim, na derradeira etapa do procedimento trifásico, como requerido pelo próprio d. órgão acusatório, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, e não havendo prova de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, e considerando ainda a reduzida quantidade de droga apreendida (11,73 gramas de maconha), as penas devem ser reduzidas, nos termos do art. 33, § 4º, da

Lei nº 11.343/06 (privilégio), no grau máximo de 2/3 (dois terços), perfazendo assim o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Insta consignar, por oportuno, que o Colendo Supremo Tribunal Federal já assentara o entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90.

De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, que possuía entendimento sumulado em sentido diametralmente oposto ao acima descrito, cancelou o Enunciado 512 de sua Súmula, alinhando-se à jurisprudência do Pretório Excelso.

E, por fim, recentemente a legislação em vigor veio a contemplar referido posicionamento, consoante se infere do teor do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, acrescido pela Lei nº 13.964/19, que dispõe, in verbis:

"Art. 112 (...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Desse modo, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu será cumprida inicialmente em regime prisional aberto, tendo em vista o quantum da reprimenda e a ausência de circunstâncias capazes de justificar a imposição de regime mais gravoso.

Outrossim, no tocante à substituição da pena carcerária por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No caso em exame, faz jus o imputado à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44, § 2º, do Código Penal, já que preenche os pertinentes requisitos legais para a substituição.

Assim, converto a pena corporal acima aplicada em penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (arts. 43, inciso IV, e 46, ambos do CP), pelo mesmo prazo da pena reclusiva (art. 55 do CP), e de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social desta comarca (arts. 43, inciso I, e 45, § 1º, ambos do mesmo codex), a serem especificadas na fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu LEONARDO GABRIEL DE ABREU à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da primeira por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e por prestação pecuniária, na forma retroespecificada, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Em caso de descumprimento do benefício da substituição, o regime prisional inicial de cumprimento da pena carcerária será o aberto.

Tendo em vista sua manifesta origem ilícita, decreto o perdimento do celular apreendido em poder do réu (cf. auto de fl. 12), com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Autorizo, porém, após o trânsito em julgado, a restituição, em favor da testemunha Lucas Lopasso de Araújo, do numerário com ela apreendido (cf. auto de fl. 12 e guia de fl. 74).

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 7 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA